

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל**

תובעת: **ורד כהן מיכאלי**
באמצעות ב"כ עוה"ד שירי בויארסקי סבג
- נגד -

נתבעת: **יפעת נרקיס**
באמצעות ב"כ עוה"ד בן – נון עידית

פסק דין

1. עניין לנו בסכסוך הנוגע לבית המשותף שברחוב כ"ג יורדי הסירה 3, הרצליה הידוע כגוש 6520 חלקה 3 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. הבית מורכב משלושה מבנים: מבנה 1 ובו 5 דירות, מבנה 2 ובו 4 דירות ומבנה 3 ובו 6 דירות. בסך הכל מכיל הבית 15 דירות. כן נרשם לבית תקנון מוסכם.
3. התובעת היא בעלת דירה בקומה השלישית של מבנה מס' 2 של הבית הידועה כחלקת משנה 9.
4. הנתבעת היא בעלת דירה בקומת הקרקע של מבנה מס' 2 של הבית הידועה כחלקת משנה 6.
5. בתביעה התבקש להורות לנתבעת לסלק ידה מהרכוש המשותף של הבית, וכן להשיב את המצב לקדמותו.

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית

6. הנתבעת השתלטה על חלקים מהרכוש המשותף של הבית שלא כדין, כמפורט להלן: גידרה שטח של 172 מ"ר וסגרה אותו בשער בחלקו הדרומי האחורי של מבנה 2 של הבית, כך שאיש מלבדה אינו יכול להיכנס ולעשות שימוש בשטח האמור, בנתה סככה בשטח של 44 מ"ר בחלקו הדרומי של הבית, הציבה מחסן וחניה פרטית בחלקו המערבי של הבית, סללה שביל בטון בחלקו המערבי של הבית המוביל מהחצר שגידרה ועד לחניה, שתלה עצים בסמוך לקיר המערבי של הבית בקרבת צינורות מים וביוב, בשטח בו עושה הנתבעת שימוש ייחודי מצויות שוחות הביוב המשרתות את כלל דירות הבית, ולא ניתן לטפל בהן אלא בתיאום עם הנתבעת ובהסכמתה.

7. ביום 19.5.03 פנו הנתבעת ומי שהיה אז בעלה, לבעלים הקודמים של דירת התובעת ולשאר בעלי הדירות בבית המשותף בבקשה לבצע מספר פעולות בחצר המשותפת, בין היתר ובעיקר, על מנת לאפשר לילדיהם שהיו אז קטנים, ולכלבים שברשותם, להסתובב בחצר בבטחה, והגיעו עמם להסכמות.
8. אלא, שהנתבעת הפרה את ההסכמות שעוגנו בינה ובין בעלי הדירות, וביום 9.11.03 הודיעו בעלי הדירות לנתבעת על ביטול ההרשאה שנתנו לה, זאת חודשים ספורים לאחר שניתנה על ידם.
9. ילדיה של הנתבעת כבר גדלו, ואין שום סיבה להמשיך ולאפשר לה להשתלט על הרכוש המשותף.
10. בעלי הדירות פנו במהלך השנים למס' גורמים ביניהם: הנתבעת, האגודה לתרבות הדור, מהנדס העיריה ועוד, בדרישה להסיר את הפלישה, אך לא נענו.
11. לאורך השנים, פנתה התובעת מס' רב של פעמים בעל פה לנתבעת, באמצעות אביה, בדרישה להסרת הפלישה, ואולם הנתבעת התעלמה מפניותיה, ולא שיתפה פעולה.
12. בשים לב לכך שלא ניתנה לנתבעת הסכמת כל בעלי הדירות לשימוש האמור, שימוש זה הוא שימוש ייחודי שלא כדין.
13. גם אם יקבע כי ניתנה לנתבעת רשות ולו זמנית לשימוש שהיא עושה ברכוש המשותף, כמפורט לעיל, הרי שמדובר ברשות חנם שניתן לבטלה בכל עת, וזו בוטלה על ידי בעלי הדירות למצער ביום 9.11.03, עת שלחו בעלי הדירות מכתב לנתבעת ולמי שהיה במועד האמור בעלה בו הודיעו על ביטול ההרשאה.

טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית

14. התובעת רכשה את דירתה כאשר המצב המפורט בכתב תביעתה היה קיים. משכך מנועה התובעת מלהגיש את התביעה, ויש להורות על מחיקתה.
15. דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות ו/או שיהוי רב בהגשתה, שכן המדובר ברשות שימוש שניתנה לנתבעת על ידי בעלי הדירות בבית עוד בשנת 2003.
16. מיום קניית דירתה ועד למועד בו הוגשה התביעה נמנעה התובעת לדרוש את סילוק ידה של הנתבעת, והתביעה הוגשה רק בשל סכסוך שהתגלע בין השתיים. התביעה הוגשה בחוסר תום לב תוך שהתובעת עושה שימוש לרעה בהליכי משפט.
17. הנתבעת עושה שימוש בחצר המשותפת של הבית בהסכמת בעלי הדירות החל מיום 19.5.2003.
18. שטח החצר בו עושה הנתבעת שימוש ייחודי היה מוזנח ומלוכלך בחומרי בניין ישנים כגון צינורות ישנים וחלודים, וכן היווה סכנה תברואתית היות ופתחי הביוב היו שבורים,

צחנה עלתה מן הבורות, והחצר שרצה מקקים ומיני מזיקים שונים. בעלי הדירות בבית מעולם לא עשו שימוש בחלק זה של החצר בשל קיומן של שוחות ביוב, והם אף גידרו אותו בגדר חיה על מנת ליצור חייץ בינו ובין שטח החצר המטופחת בחלקו הקדמי של הבית.

19. נוכח המצב המתואר ביצעו הנתבעת ובעלה דאז מספר פעולות בחצר האחורית הסמוכה לדירתם כגון: גידור החצר, גידור בורות השופכין, ריצוף החצר מחשש לקריסה של שוחות ביוב, ניקוי פסולת בחצר, טיפוח הגינה, הקמת סככת צל דקורטיבית. פעולות אלה נעשו לבקשת בעלי הדירות שגרו באותה עת בבית.

20. העבודות הנ"ל בוצעו על ידי הנתבעת ובמימונה. בתמורה לכך קיבלה הנתבעת את הסכמת בעלי הדירות לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת, ובעלי הדירות זכו מצדם בחצר נקייה ומטופחת בלא ששילמו על כך. מאז ועד היום שטח החצר בו הנתבעת עושה שימוש ייחודי מתוחזק על ידה ובמימונה.

21. באסיפת בעלי דירות שהתקיימה בשנת 2005 נתנו בעלי הדירות בבית את הסכמתם כי הנתבעת תמשיך לעשות שימוש בחצר המשותפת, ומוכחשת הטענה כי הם ביטלו את ההרשאה שניתנה לנתבעת לעשות שימוש בחצר האמורה עוד בשנת 2003.

22. בשנת 2005 נתנו הדיירים את הסכמתם להקמת 2 מקומות חניה לשימושן הייחודי של הנתבעת ומשפחת זמרי שמכרה את דירתה לתובעת. החניות הוקמו בצדו הצפון מערבי של הבית במימון של משפחת זמרי ושל הנתבעת. סילוק ידה של הנתבעת משטח החניה בו היא עושה שימוש ייחודי בהכרח יביא גם לסילוק ידה של התובעת משטח החניה בו היא עושה שימוש ייחודי.

23. בעלי הדירות נתנו לנתבעת את הסכמתם לבניית מחסן בחצר המשותפת לשימושה הייחודי.

24. התובעת אינה מעוניינת לעשות שימוש בחצר מושא התביעה מאחר ודירתה מצויה בקומה האחרונה של הבית, ובשנים האחרונות היא אינה מתגוררת בבית, אלא משכירה את דירתה.

25. התובעת ניסתה במשך זמן רב לשכנע את יתר בעלי הדירות להצטרף לתביעה, ואולם הדבר לא עלה בידה.

26. הצדדים הגישו ראיותיהם, וכן נשמעו עדיהם. בנוסף, נערך על ידי ביקור במקום ביום 5.3.2020 על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים, שעל ממצאיו אעמוד בהמשך. כן הוגשו סיכומי טענות הצדדים. עתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

27. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה, מהנימוקים שיפורטו להלן:

המסגרת הנורמטיבית

28. "רכוש משותף" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כדלקמן: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, לרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מריבתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

29. סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין קובע כי: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).

30. בנוסף, סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

31. משילובם של סעיף 62 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

32. שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש משותף, כמוהו כ"הצמדה בפועל". כאשר בעל דירה תופס חזקה ייחודית ברכוש המשותף, הוא מונע בכך לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף. לכך, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה: ת"א (מחוזי- ת"א) 2816/03, קונצ'יצקי נ' שפלן (פורסם בנבו, 3.4.06), ע"א 2525/92, ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 114-115).

33. מהי, אם כן, "ההסכמה" הנדרשת? נקבע, כי כאשר עסקינן בויתור על זכויות קנייניות נדרשת הסכמה מפורשת וברורה ואין די בהסכמה שבשתיקה או בהסכמה משתמעת (ראה: ע"א 7388/97 עזבון משה שמיר ז"ל נ. דולב (שמיר), פ"ד נה 690). עוד הוכרע כי אין צורך בהסכמה בכתב וגם הסכמה על פה הסכמה היא (ראה: ר"ע 815/81, כליפא נ' שאול, פ"ד לו (3) 78, ע"א (מחוזי- ת"א) 1020/03, בובליל נ' שטיינר (פורסם בנבו, 24.2.04).

34. כאשר עסקינן במתן זכות שימוש ייחודית במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), אזי ניתן ללמוד על הסכמה, גם על דרך של הסכמה שבשתיקה, הסכמה מכללא, על דרך

בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים (ראה: ע"א 32/77, טובליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, לומברוזו נ' קובנר (פורסם בנבו, 7.8.07).

35. העובדה שעבר **זמן רב** מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא. בפס"ד בעניין טובליצקי לעיל נקבע בעניין זה כך: "**לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה, התנהגותם של בעלי הדין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא (implied license) שלא היה קיים מלכתחילה...**".

36. יפים לעניין זה גם דבריה של פרופ' נינה זלצמן: "**לצד רשות שניתנה בהבטחה מפורשת ניתן לתאר מצבים שבהם נלמדת הסכמתו של בעל מקרקעין, ומכאן רשותו, משתיקתו ואי מחאתו על ההחזקה של פלוני בנכס, או על השימוש שהוא עושה בנכס, כאשר בנסיבותיו של המקרה ניתן היה לצפות את התנהגותו. במצבים אלה ההחזקה או השימוש הושגו במעשה עוולה של הסגת גבול במקרקעין. אך השלמתו של בעל מקרקעין עם נוכחותו של פלוני בנכס מניחה עם עבור הזמן את הסכמתו שבשתיקה... הסכמה זו משמעותה היתר של רצון טוב המתחדש מרגע לרגע כל עוד לא גילה בעל המקרקעין את דעתו שהוא חפץ בסיומו...**" (ראו פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב' חוברת א', בעמ' 128- להלן "זלצמן").

37. להבדיל מהסכמה למתן זכות קניינית, רשות מכללא היא זכות אישית, ממנה ניתן לחזור בכל עת. ראה ע"א 50/77, מזרחי נ' אפללו, פ"ד ל"א (3): "**מסיג גבול שמחזיק בקרקע תקופה ממושכת בידיעת הבעלים ובלי שהבעלים יפעלו לסילוקו, עלול להיהפך לבר רשות ללא תמורה או בר רשות חינם ובעל המקרקעין רשאי לבטל רשות זו בכל עת**".

38. ראה גם פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב', 24, 57: "**רשות שנלמדה מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינם המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני**".

39. הלכה זו תקפה, ואף ביתר שאת, ביחס למתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של הבית המשותף. בהקשר לכך, ובהתחשב בטיב היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, יש להקפיד הקפדה יתירה לשמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, ויש להישמר ביותר לבל תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה ממנה לא ניתן יהיה לחזור. ראה

לעניין זה ע"א (מחוזי ת"א) 271/85, הילמן נ' רוזן (פורסם בנבו, 14.9.86): "מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתיים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות זו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה".

40. בפסיקה נקבע כי רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, יהיו נותני הרשות מנועים מלחזור בהם מההרשאה אותה נתנו, והרשות שניתנה על ידם תהא בלתי הדירה. יפים לעניין זה דברים שנאמרו בעניין קונצ'יצקי לעיל: **בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף, יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה...ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינוס שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון... על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות...**"

ראה גם: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127.

מן הכלל אל הפרט

41. לצורך הוכחת הפלישה הנטענת, הוגשה מטעם התובעת חוות דעתו של המודד אליאס חורי לה צורפה מפת מדידה (סומנה ת'2). הנתבעת לא הגישה חוות דעת נגדית. המודד אליאס נחקר על חוות דעתו, והאמור בה ובמפת המדידה לא נסתרו (חוות הדעת ומפת המדידה יקראו להלן: "חוות דעת המודד").

42. ממסמכי רישום הבית המשותף, מחוות דעת המודד ומביקורי במקום, עולה כדלקמן:

א. חזית הבית פונה לרחוב כ"ג יורדי הסירה בהרצלליה.

ב. במבנה 2 של הבית קיימת קומת עמודים, כשבקומת הקרקע בנויה דירת הנתבעת.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/35/2018

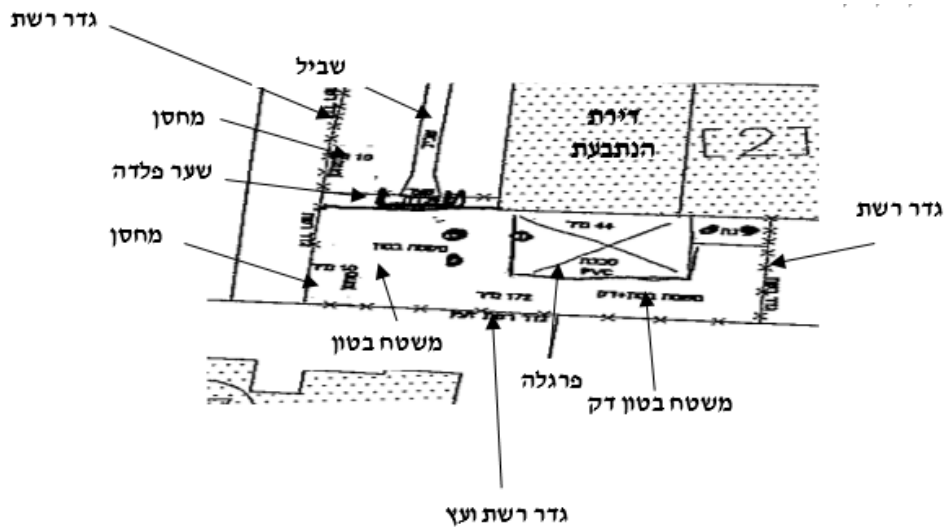
מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק מקרקעין

- ג. דירת התובעת מצויה בקומה השלישית של מבנה 2 של הבית.
- ד. חצר הבית אינה צמודה למי מדירות הבית, ונכללת ברכוש המשותף של הבית.
- ה. החצר העורפית סמוכה בחלקה לדירת התובעת. קיימת יציאה אליה באמצעות דלת ויטרינה מדירת הנתבעת.
- ו. על גבי הקיר החיצוני בחלקו הדרומי של מבנה 2 של הבית (זה הפונה לחצר), בנויה פרגולה רחבת מימדים. בהתאם לחוות דעת המודד גודלה של הפרגולה הוא 44 מ"ר. תחת הפרגולה הוצבו שולחן אוכל עם כסאות.
- ז. החצר תחומה בגדר שחלקה עשויה מרשת וחלקה מבמבוק (להלן: "הגדר"). שטח החצר המגודר עומד על 172 מ"ר (ראה חוות דעת המודד) (להלן: "החצר").
- ח. קיימת כניסה נוספת לחצר באמצעות שער ברזל נעול (להלן: "שער הברזל"). הגישה לשער זה היא באמצעות שביל גישה מבוטן המצוי בחצר הבית הקדמית.
- ט. על גבי חלק שטח החצר נוצק משטח בטון וביתר החצר נבנה משטח דק.
- י. בתחומי החצר נצפו מיטלטלין רבים הכוללים: ספות, מכונת ייבוש, שולחנות, וכיסאות, מחסן, כבסי תליה, אופניים, ערסל ועציצים.
- יא. בתחומי החצר שוחות ביוב המשמשות את כלל בעלי הדירות בבית.
- יב. בתחום החצר ניצב מחסן המשמש את הנתבעת. מחוץ לחצר בצדו המערבי של הבית ובסמוך לשער הברזל קיים מחסן נוסף בשטח הנכלל ברכוש המשותף המשמש אף הוא את הנתבעת.
- יג. בחצר הקדמית, בצדו המערבי של הבית, נוצק משטח מקורה בסככה המשמש לחניה המשמשת את הנתבעת. החניה מצויה על שטח החצר הנכלל ברכוש המשותף של הבית. לצד חניה זו מצויה חניה שאינה מקורה, שעל פי הנטען משמשת את התובעת.
- יד. מצאתי לצרף להלן את הסימונים שסומנו על גבי מפת המדידה שצורפה לחוות דעת המודד. הללו עולים בקנה אחד עם ממצאיי בביקורי במקום (ראה ת'2):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/35/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק מקרקעין



43. אין מחלוקת בין הצדדים כי הגדר ושער הברזל נבנו על ידי הנתבעת, וכי כל המיטלטלין שבתחומי החצר שייכים לנתבעת ומשמשים רק אותה. אין גם מחלוקת בין הצדדים כי רצפת הבטון והדק שבחצר הוקמו על ידי הנתבעת.

44. מחקירתה הנגדית של הנתבעת עלה כי שער הברזל נעול כך שהכניסה לחצר אפשרית רק מדלת הוויטרנה שבדירת הנתבעת. ראה פרוטוקול מיום 28.4.2019 עמ' 5, שורות 1-7: "ש. איך השער הזה נעול? ת. הוא נעול מבפנים. אין מנעול בכלל. זה שער ישן שקנינו מירושלים בזמנו. עכשיו צריך לצבוע אותו שוב, אבל הוא יפה ויש לו נעילה מבפנים ולא מבחוץ. ש. כך שאת לא יכולה להיכנס? ת. רק מבפנים, מבחוץ אני לא יכולה. ש. רק כשאת בחצר את יכולה לפתוח מבפנים אם מישהו רוצה להיכנס ולסגור ת. כן אלא אם השארתי אותו פתוח. זה כמו דלת שנטרקת".

45. עוד עלה מחקירתה הנגדית של הנתבעת כי בעל דירה המבקש להיכנס לחצר נדרש לבקש ממנה לאפשר לו כן, לרבות לצורך טיפול בשוחות הביוב: ראו פרוטוקול מיום 28.4.19, עמ' 8, שורה 14: "אשמח שמי שרוצה להיכנס ייכנס, שיתקשר אלי, שיבקש, ואני אפתח לו את השער". וכן שורות 22-23: "אם למשל כמו שקרה שהפילו דברים מהגג אין בעיה שיכנסו וייקחו את מה שנפל או אם יש בעיה העם בורות הביוב".

46. הנתבעת אישרה בחקירתה הנגדית כי השימוש שהיא עושה בחצר הוא שימוש ייחודי. ראה פרוטוקול מיום 28.4.19, עמ' 8 שורות 26-32: "ש. מבחינתך את עושה בשטח מנהג בעלים, אם למישהו נופל משהו תתירי לו להיכנס, אבל לא תתירי לאף אחד לעשות שימוש? ת. לא. אין שום מקום לזה. החצר הזו ניתנה לשימושי. ש. הבלעדי ת. לשימושי במצב שקיים. ש. הבלעדי אני שואלת ת. כן, אחרי אחריות והוצאות רבות".

47. נוכח כל האמור לעיל מוצאת אני לקבוע כי השימוש שעושה הנתבעת בחצר הוא שימוש ייחודי. שימוש זה עולה כדי "הצמדה בפועל" והוא מחייב את קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית.

האם הסכימו כל בעלי הדירות לשימוש הייחודי הנעשה על ידי הנתבעת בחצר

48. כמפורט לעיל, הנתבעת גידרה את החצר והקימה שער המונע משאר בעלי הדירות להיכנס לשטח החצר, ריצפה את החצר, הציבה מיטלטלין רבים (כגון: שולחנות, כיסאות, מתקן כביסה, ספות ומיטלטלין נוספים, כמפורט ברשמי הביקור במקום, ראה לעיל), סללה שביל בטון המוביל לשער הכניסה לחצר, הקימה מחסנים ופרגולה. פרק זה יעסוק בכל אותם שימושים אותם עושה הנתבעת בחצר, כמפורט לעיל, למעט בכל הנוגע להצבת מחסנים ופרגולה והקמת חניה אשר לגביהם יבוא פרק נפרד.

הסכמה בכתב

49. בתקנון המוסכם החל על הבית לא נכללת הוראה המורה כי הרכוש המשותף של כל מבנה יוצמד לאותו המבנה. הפועל היוצא הוא שהרכוש המשותף שייך לכלל בעלי הדירות בבית בכל המבנים.

50. הנה כי כן, נדרשת הסכמתם של כל 15 בעלי הדירות בבית לשימוש הייחודי הנעשה על ידי הנתבעת. העובדה כי החצר הייתה מוזנחת, כטענת הנתבעת, ו/או כי בעלי הדירות אינם מתגוררים בדירה או אינם עושים בחצר זו שימוש, כטענת הנתבעת, אין בה כדי לאיין את הצורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית לשימוש הייחודי הנעשה ע"י הנתבעת בחצר.

51. הנתבעת טענה כי יש בידה הסכמה בכתב לשימוש הייחודי אותו היא עושה בחצר ובכלל זה הסכמת משפחת זמרי, שאין חולק כי מכרו את דירתם לתובעת (להלן: "זמרי"). לצורך הוכחת טענה זו הגישה הנתבעת שני מסמכים: האחד, מסמך מיום 19.5.03 החתום בידי מי שהיו בעלי דירות במבנה 2 של הבית במועד האמור, ובכלל זה ה"ה זמרי (צורף כנספח 1 לתצהירה של הנתבעת) (להלן: "המסמך מיום 19.5.03"). והשני, פרוטוקול אסיפת בעלי דירות של מי שהיו בעלי דירות במבנה 2 של הבית מיום 10.1.05, ובכלל זה זמרי (להלן: "פרוטוקול האסיפה מיום 10.1.05"). נבחן להלן מסמכים אלו:

המסמך מיום 19.5.03

52. האמור במסמך מיום 19.5.03 יצוטט להלן: "אנו, משפחת נרקיס (הנתבעת הוספה שלי א.ש) הדיירים החדשים בקומת הקרקע בבניין שבסמטת הכ"ג 3 בהרצליה, מבקשים את הסכמת הדיירים שבבניין, שהוא במעמד של בית משותף, לביצוע עבודות בחצר האחורית הצמודה לדירה שרכשנו:

1. גידור השטח בחצר האחורית - מצד מזרח, מערב ודרום, בגובה שיבטיח את מניעת יציאתם של הילדים ושל הכלבים באופן חופשי מתחום החצר האחורית.
2. גידור מיוחד של בורות השופכין שבחלקה שהאחראיות עליהם חלה על כל דיירי הבית.
3. ריצוף חלק מהחצר האחורית, כדי שהילדים יוכלו להסתובב בחצר בביטחון.
4. טיפוח הגינה בחצר האחורית ע"י משפחת נרקיס ובמימונה.
5. הקמת סככת צל דקורטיבית.
6. גישה חופשית להחלפת בלוני גז. הובטח למשפחת גדליהו, שהבלונים שלהם מצויים בשטח שיוגדר.
7. במקרה שנביחות הכלבים יהוו מטרד למנוחת השכנים מתחייבת משפחת נרקיס להרחיק אותם מהשטח. המדובר בין השעות 06:00-23:00.
53. תוכנו של מסמך זה לא נסתר, וממנו עולה כי הפניה לבצע את הפעולות המפורטות בו נעשתה על ידי הנתבעת, וטענתה כאילו הדרישה הייתה של בעלי הדירות אינה עולה בקנה אחד עם האמור בו.
54. עוד עולה ממסמך זה כי ניתנה לנתבעת, לכל היותר, הסכמה של מי שהיו בעלי הדירות במבנה 2 של הבית בשנת 2003 לביצוע הפעולות המפורטות בו. לא נטען, וממילא, לא הוכח כי ניתנה לה הסכמת כל בעלי הדירות בשלושת המבנים של הבית כפי שנדרש לצורך קבלת שימוש ייחודי בשטח משותף.
55. התובעת טענה כי הפעולות שנעשו על ידי הנתבעת בחצר חרגו מההסכמה שניתנה לה במסמך מיום 19.5.03, וכפועל יוצא זמרי ובעלת דירה נוספת הגב' שושנה גדליהו (להלן: "גדליהו"), חזרו בהם מההסכמה מספר חודשים לאחר מכן.
56. כראיה לכך, הגישה התובעת מסמך מיום 9.11.03 בו הודיעו זמרי וגדליהו לנתבעת באמצעות ב"כ, עו"ד קדם, בין היתר, כדלקמן: **".. לנוכח השימוש לרעה אשר עשיתם בהרשאה שקיבלתם ממרשיי ביום 19.5.03 אשר עולות עד כדי קביעת עובדות חד צדדיות של ייחוד זכות השימוש והחזקה לכם בלבד בחלקים אשר ברכוש המשותף לכלל הדיירים מרשיי מודיעים בזאת על ביטול ההרשאה הנ"ל"** (ראה סעיף 8 למסמך מיום 9.11.03 אשר צורף כנספח 3 לתצהירה). הפעולות שנעשו על ידי הנתבעת ואשר חרגו מן ההרשאה שניתנה לה פורטו בסעיף 4 למסמך האמור וכללו בין היתר: הצבת מחסן, הקמת שער והקמת מתקן כביסה. בחקירתה הנגדית הודתה הנתבעת כי היא קיבלה את המכתב מיום 9.11.03, ולא הכחישה כי ביצעה פעולות אלה (ראה פרוטוקול מיום 28.4.19, עמ' 9, 18-20). פעולות אלה ניכרות היטב בשטח, כפי שהתרשמתי בביקורי במקום, ויש בהן כדי להעיד כי הנתבעת נוהגת מנהג בעלים בחצר, ולא לכך ניתנה הסכמת בעלי הדירות במסמך מיום 19.5.03.

57. בשים לב לכך, שהפעולות שבוצעו בחצר בפועל חורגות מעבר להרשאה שניתנה לנתבעת ע"י זמרי וגדליהו במסמך מיום 19.5.03, מוצאת אני לקבוע כי ביטול ההרשאה על ידם נעשה כדין.

פרוטוקול אסיפה מיום 10.1.05

58. עוד טענה הנתבעת כי באסיפת בעלי הדירות שהתכנסה ביום 10.1.2005 הסכימו כל בעלי הדירות שבמבנה 2 של הבית, ובכלל זה גדליהו וזמרי, שהנתבעת תמשיך לעשות את השימוש שהיא עושה בחצר.

59. לצורך הוכחת טענתה זו צירפה הנתבעת את פרוטוקול האסיפה מיום 10.1.05, ממנו עולה כי נכחו באסיפה זו מי שהיו בעלי הדירות במבנה 2 של הבית במועד האמור הם ה"ה: גדליהו, זמרי, זרצקי ונרקיס. ההחלטות שהתקבלו באסיפה יובאו להלן: (הפרוטוקול צורף כנספח 2 לתצהירה של הנתבעת, ותוכנו לא נסתר) (להלן: "פרוטוקול מיום 10.1.05"):

"1' הורדת גדרות רשת הנמצאות בחזית הצפונית של הבית.

2. לתת הוראות לגנן לנקות את הצמחייה בפינה הצפון מערבית.

3. הקמת גדר בגבול המערבי בין 3-5. הגדר תוקם ע"י גיא (בעלה לשעבר של הנתבעת. הוספה שלי א.ש.) לאחר ניקיון הצמחייה במקום.

4. גיא יקים מחדש את הגדר שתוחמת את החצר האחורית בקו הדרומי של הבניין בהקדם האפשרי.

5. הקמת 2 מקומות חניה בצדו הצפון מערבי של הבית במימון 2 המשפחות שתחננה שם. גיא יכשיר את החניות. הסכמתו של זמרי נתונה מראש לכך.

6. שושנה גדליהו ממשיכה לכהן כנציגות הבית.

7. השארית המחסן של גיא נרקיס (בעלה לשעבר של הנתבעת. הוספה שלי א.ש.) במקומו (3 בעד, מרי נגד)."

60. הנה כי כן, מהפרוטוקול עולה כי, לכל היותר, ניתנה הסכמת בעלי הדירות שבמבנה 2 של הבית, להקמת גדר, כאמור בסעיפים 3 ו-4 לפרוטוקול (באשר להחלטות שהתקבלו ביחס למחסן והחניות, ראה דיון נפרד בהמשך), ודין טענת הנתבעת כי באסיפה זו הסכימו בעלי דירות אלה לאפשר לנתבעת להמשיך לעשות שימוש ייחודי בחצר להידחות.

61. משהוכח, אפוא, כי זמרי חזרו בהם מההסכמה שניתנה על ידם במסמך מיום 19.5.03 וכי ניתנה על ידם, לכל היותר, הסכמה להקמת גדר, אבחן להלן האם ניתן לראות בזמרי כמי שנתנו הסכמה מכללא לשאר הפעולות שבוצעו על ידה בחצר, והאם יש בכך כדי לחייב את התובעת.

רשות מכללא

62. הנתבעת העידה כי היא עושה שימוש ייחודי בחצר החל משנת 2003, ועדותה זו לא נסתרה (ראו סעיף 2 לתצהירה). התובעת רכשה, כאמור, את דירתה מאת זמרי, וזכויות הבעלות נרשמו על שמה בשנת 2010. התביעה הוגשה ביום 24.1.2018.

63. מהמועד בו תפסה הנתבעת חזקה בחצר, 2003, ועד למועד בו מכרו זמרי את דירתם לתובעת, שנת 2010, חלפו 7 שנים בלבד. "הסכמה מכללא" נלמדת, כאמור ברקע המשפטי שפורט לעיל, מחלוף זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע. אין די בהימנעות שאיננה מתפרשת על פני זמן ארוך טווח בכדי ללמוד ממנה על מתן הסכמה מכללא, שאם לא כן, הרי שכל תפיסה קצרת טווח ובמקביל הימנעות בעל הזכויות מלנקוט כנגדה פעולה מעשית, תיחשב כהסכמתו של בעל המקרקעין מכללא למתן רישיון שימוש (ראו פס"ד בעניין טובוליצקי לעיל). משכך, יש לפרש את דרישת הפסיקה ל"חלוף זמן רב" באופן שבו רק חלוף זמן ארוך במיוחד ומשמעותי מרגע תפיסת השימוש במקרקעין יוכל להעמיד את בעל זכויות המקרקעין בחזקת מי שהסכים לתפיסה זו.

64. בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, תפיסת חזקה ייחודית לפרק זמן של 7 שנים אינה מהווה "זמן רב" שיש בו כדי ליצור רישיון מכללא לשימוש האמור. לכן, אין לומר שבמועד בו רכשה התובעת את דירתה ניתנה לנתבעת על ידי זמרי הסכמה מכללא לשימוש הייחודי שנעשה על ידה בחצר.

65. לא זו אף זו, אף אם היה מוכח כי בנוסף להקמת הגדר, נתנו זמרי את הסכמתם לכל השימושים אותם עושה הנתבעת בחצר, בין בהסכמה בכתב ובין בהסכמה מכללא, אין בהסכמה זו כדי לחייב את התובעת, כפי שיפורט להלן:

66. ככלל, הסכמה תחייב גם צדדים שלישיים, היינו חליפיהם של בעלי דירה שנתנו הסכמתם רק אם ידעו על קיומה. כך נפסק לגבי מתן זכויות במקרקעין, וניתן ללמוד מקל וחומר ביחס למתן זכות שימוש במקרקעין. ראו פס"ד בעניין בובליל לעיל: **"לעמדת רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות לכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף"**.

67. לא הוכח כי התובעת ידעה אודות "דבר קיום ההסכם" הנטען בין הנתבעת ובין זמרי במועד בו רכשה את דירתה מזמרי. העובדה כי הנתבעת עשתה שימוש ייחודי בחצר במועד בו רכשה התובעת דירתה, אין בו די, שכן ממסמכי רישום הבית המשותף עולה שהחצר כולה היא רכוש משותף, כך שהתובעת רשאית הייתה להאמין כי הנתבעת היא פולשת שלא כדין אשר עשתה דין לעצמה בהשתלטה על החצר, ולכן על הנתבעת להוכיח

כי התובעת ידעה על קיומה של ההסכמה. זאת, כאמור לא הוכח. לא נטען, וממילא לא הוכח כי דבר ההסכמה נרשם בתקנון המוסכם החל על הבית או בספר ההחלטות של בעלי הדירות בבית בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק המקרקעין המורה כי "החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה". כן ראה פס"ד בעניין כליפא לעיל "הדגש שבו" (סעיף 71 לחוק המקרקעין, א.ש.). הוא על הרחבת ההסכמה, שהסכימו בעלי הדירות בהווה, והחלטה גם על מי שירכוש בעתיד דירה מן הדירות שבבית. הרחבה כזאת, תיתכן, רק אם ההסכמה ניתנה בצורת החלטה, שנרשמה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, ולשם כך גם מעניק סעיף 71 את זכות העיון בספר הפרוטוקולים לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף".

68. הנתבעת גם לא הביאה את זמרי לעדות על מנת להוכיח שהתובעת ידעה על קיומה של ההסכמה. כלל ידוע הוא כי צד להליך שנמנע מהבאת עד או ראיה רלוונטית ייחשב הדבר כנגדו. הלכה זו יסודה בניסיון החיים ובשכל הישר. צד הרוצה לשכנע בטענותיו, וישנן ראיות העשויות לסייע לו בכך, עליו לדאוג להבאתן בהקדם. משלא עשה כן, פועל הדבר לחובת גרסתו. ראה לעניין זה: ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו, פד"י מה(4) 651, 660.

69. בסיכומיה טענה הנתבעת כי התובעת ידעה על ההסכמה האמורה, ולצורך הוכחת טענתה זו הפנתה לעדותה של התובעת בחקירתה הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 28.4.2019, עמ' 2, שורות 17-19: "ש. ידוע לך שבשנת 2003 ובשנת 2005 הייתה הסכמה גורפת של כל הדיירים בזמן שאת גרת בדירה הזו" ת. ידוע לי שב - 2003 הייתה הסכמה". התובעת לא נשאלה מתי נודע לה על ההסכמה. מעדותה זו של התובעת לא שוכנעתי כי התובעת ידעה אודות ההסכם במועד בו רכשה את הדירה, ולא הובאה כל ראיה להוכיח כאמור והיא גם לא נחקרה אודות היקף ההסכמה ומשכה. ויוטעם, בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, הידיעה אודות קיום ההסכם נדרשת להיות במועד בו רכש הבעלים החדש את הדירה.

70. מהמועד בו רכשה התובעת את דירתה, 2010, ועד למועד בו הוגשה התביעה 24.1.18 חלפו 8 שנים. בנסיבות אלו אינני סבורה כי קמה לגבי התובעת חזקת "ההסכמה מכללא", שכן לא חלף זמן רב מהמועד בו רכשה התובעת את דירתה ועד להגשת התביעה דנן. לפיכך, הימנעותה של התובעת מלפעול כנגד הנתבעת במהלך פרק זמן זה, אין משמעה הסכמה מכללא לשימוש שעושה הנתבעת בשטח המחלוקת. מטעמים אלה מצאתי לדחות את טענת השיהוי וההתיישנות שנטענה על ידי הנתבעת. עוד מצאתי

להוסיף כי "פלישה" מהווה "אירוע מתמשך" המוליד במהלך התרחשותו עילות תביעה מתחדשות, ואינו חוסם הגשת תביעה (ראה ע"א 9413/03, אלנקווה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים (פורסם בנבו, 22.6.08), ואף מטעם זה דין הטענות לשיהוי והתיישנות להידחות.

האם הנתבעת שינתה מצבה לרעה

71. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף, כי אפילו היה מוכח כי יש לראות בתובעת כמי שהסכימה מכללא לשימוש שנעשה על ידי הנתבעת בחצר, הרי שהיא הייתה רשאית לבטל הרשאה זו, שכן, כמפורט לעיל, רק במקרים מיוחדים, בהם יש להגן על אינטרס ההסתמכות, ניתן לקבוע כי הרישיון שניתן לבעל דירה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, הוא בלתי הדיר. לא מצאתי כי מקרה זה נכלל במקרים אלה, בשים לב לכך שלא הוכח כי הנתבעת הוציאה סכומים מהותיים בגין העבודות שביצעה בשטח זה, ולא הוכח כי קיים אינטרס לגיטימי של הנתבעת עליו יש להגן, זאת במיוחד נוכח העובדה כי הנתבעת נהנתה משימוש ייחודי בחצר, ששטחה 172 מ"ר (ראה מפת מדידה וחוות דעת המודד מטעם התובעת, אשר לא נסתרו) משך 15 שנים ללא כל הפרעה.

72. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, על הנתבעת לסלק ידה מהחצר, להסיר את הגדר ואת שער הברזל שנבנה על ידה באופן כזה שהחצר תיוותר פתוחה לחלוטין, ולפנות את כל המיטלטלין שבבעלותה בחצר זו, והכל על חשבונה בתוך 90 ימים מהיום.

73. מאחר שאין בריצוף הבטון והדק שבחצר כדי תפיסת חזקה ייחודית בחצר, אינני רואה להורות על הריסתם. הוא הדין לגבי שביל הגישה המבוטן לחצר. עם זאת, בהיותם רכוש משותף, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטות לעניין שטחים אלה, ובכללן להחליט על הריסתם, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

מחסנים

74. כמפורט, ברשמי מביקורי במקום ובמפת המדידה של המודד מטעם התובעת, בשטח הנכלל ברכוש המשותף של הבית הוצבו שני מחסנים, שאין חולק שנבנו על ידי הנתבעת. האחד, בתחום החצר, והשני, מחוץ לחצר ובסמוך לשער הברזל.

75. בפסיקה נקבע כי הקמת מחסן ברכוש המשותף עשויה להיחשב כ"הרחבת דירה" במובן סעיף 71 לחוק המקרקעין, ככל שהמחסן מהווה המשך טבעי ופיזי לדירה המורחבת (ראה רע"א, 1462/10 עטייה נ' שגיא (פורסם בנבו, 2.8.12). ואולם, המחסנים מושא ההליך אינם מצויים בסמיכות פיזית לדירתה של הנתבעת, ואין בינם ובין דירתה כל קשר פיזי. משכך הם אינם מהווים "הרחבת דירה".

76. בשים לב לכך ששטחי הרכוש המשותף לא הוצמדו בתקנון המוסכם החל על הבית למבנים השונים של הבית, הרי שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות שבשלושת המבנים,

להקמת המחסנים, וזו לא הוכחה. במסמך מיום 19.5.03 (ראה ציטוט לעיל) לא מוזכרים כלל המחסנים, ולא ניתנה הסכמה להקמתם גם לא על ידי בעלי הדירות של מבנה 2 החתומים על המסמך האמור (אפילו הייתה ניתנת הסכמתם, אין בה די, מהטעמים שפורטו לעיל). בפרוטוקול מיום 10.1.05 הוחלט ברוב של בעלי הדירות שבמבנה 2 של הבית על "השארות המחסן של גיא נרקיס (בעלה לשעבר של הנתבעת). הוספה שלי א.ש.) במקומו". אולם, להקמת מחסנים אלו נדרשת ממילא הסכמת כל בעלי הדירות, וזו כאמור לא ניתנה.

77. לא זו אף זו, מהפרוטוקול מיום 10.1.05 עולה כי ה"ה זמרי, שמכרו, כאמור, את דירתם לתובעת התנגדו להותרת המחסן, ופעלו להסרתו עוד קודם לשנת 2005 (ראה מסמך מיום 17.5.2004 מאת ב"כ זמרי למהנדס עיריית הרצליה, צורף כנספח 3 לתצהירה של התובעת, ולא נסתר).

78. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, על הנתבעת להסיר על חשבונה את המחסנים, וזאת בתוך 90 ימים מהיום.

פרגולה

79. כמפורט ברשמי מביקורי במקום ובמפת המדידה של המודד מטעם התובעת, על גבי הקיר החיצוני בחלקו הדרומי של מבנה 2 (זה הפונה לחצר) בנויה פרגולה רחבת מימדים בשטח של 44 מ"ר. אין מחלוקת כי פרגולה זו נבנתה על ידי הנתבעת.

80. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, קובע כדלקמן: "(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה. (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת. (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו".

81. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו, 20.5.66) עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיעה בסעיף 2 לעיל: "כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם".

82. בע"א 395/74, לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2), 39, נקבע: "כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה, ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת... אמרנו שאין נפקא מינה אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם."

83. הנה כי כן, התקנון המצוי אוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הגורמים ל"פגיעה" ברכוש המשותף או בדירה אחרת. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, ולא כפגיעה פיזית דווקא.

84. שאלת הפגיעה נבדקת, בין היתר, בהתאם לתנאי המקום והזמן. בתוך כך, יש צורך לעמוד על אופיו וצביונו המיוחד והייחודי של הבית המשותף, ולתת את הדעת לסממנים ואלמנטים ייחודיים, כגון מיקום, גובה, גיל וכיוצא באלו.

85. התקנת הפרגולה על גבי הקיר החיצוני של מבנה 2 של הבית, בשים לב לממדיה, והאופן בו הותקנה, מהווה פגיעה כמובנה בסעיף 2 לתקנון המצוי. מאחר ושטחי הרכוש המשותף לא הוצמדו, כאמור, בתקנון המוסכם החל על הבית למבנים השונים של הבית, הרי שנדרשת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בכלל המבנים של הבית להתקנת הפרגולה.

86. במסמך מיום 19.5.03 ניתנה, לכל היותר, הסכמת בעלי הדירות במבנה 2 של הבית "להקמת סככת צל דקורטיבית", כאשר זמרי חזרו בהם, כאמור, מהסכמתם זו. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי בידי הנתבעת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בכלל המבנים של הבית.

87. משכך, אני מורה לנתבעת להסיר על חשבונה בתוך 90 ימים מהיום את הפרגולה, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של הבית, בתוך פרק הזמן האמור, להותרת הפרגולה על כנה, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

החניה

88. כמפורט ברשמי מביקורי במקום, בחצר הקדמית בצדו המערבי של הבית משטח סלול המשמש לחניה ומקורה בסככה המשמש את הנתבעת. החניה בנויה על שטח משותף (להלן: "החניה"). לצד משטח זה סלול משטח חניה נוסף, שעל פי הנתען משמש את התובעת. שטח זה אינו מקורה.

89. הנתבעת הודתה כי החניה משמשת רק אותה (סעיף 8 לתצהירה).

90. בפרוטוקול אסיפת בעלי דירות מבנה 2 של הבית מיום 10.1.05 הוחלט ביחס לחניות כדלקמן: " **הקמת 2 מקומות חניה בצדו הצפון מערבי של הבית במימון 2 המשפחות שתחננה שם. גיא יכשיר את החניות. הסכמתו של זמרי נתונה מראש לכך**".

91. פרט למסמך האמור, לא הובאה כל ראיה נוספת. פועל יוצא הוא, שבידי הנתבעת הסכמת בעלי הדירות שבמבנה 2 בלבד לשימוש הייחודי הנעשה על ידיה בחניה. ואולם, ובשים לב לכך ששטחי הרכוש המשותף לא הוצמדו, כאמור, בתקנון המוסכם החל על הבית למבנים השונים של הבית, הרי שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות שבשלושת מבני הבית לשימוש זה. לא נטען, וממילא, לא הוכח כי ניתנה הסכמה כאמור.

92. משכך, אני מורה לנתבעת לחדול מלעשות שימוש ייחודי בחניה. אינני רואה להורות על הריסת משטח החניה, ואני מורה כי משטח החניה יוותר כרכוש משותף אשר ישמש את כלל בעלי הדירות בבית. עם זאת, בהיות משטח החניה רכוש משותף, רשאית האסיפה הכללית של הבית לקבל החלטות לעניין שטח זה, ובכללן להחליט על הריסתו, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

93. באשר לחניית התובעת, היות ולא הוגשה תביעה שכנגד בעניין איני עושה סעד בעניין.

לסיכום

94. על הנתבעת לסלק ידה מהחצר ולהפסיק את השימוש הייחודי אותו היא עושה בחצר, להסיר את הגדר ושער הברזל שנבנו על ידיה, באופן כזה שהחצר תיוותר פתוחה לחלוטין, ולפנות משטח זה כל חפץ ומיטלטלין השייכים לה.

95. הנתבעת תסיר את המחסנים מושא ההליך.

96. האמור בסעיפים הנ"ל ייעשה בתוך 90 ימים מהיום ועל חשבונה של הנתבעת.

97. ריצוף הבטון, הדק, ושביל הגישה המבוטן לחצר יוותרו על כנם, אלא אם תתקבל החלטה אחרת של האסיפה הכללית של הבית, ובכלל זה החלטה על הריסתם, בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

98. הנתבעת תסיר על חשבונה בתוך 90 ימים מהיום את הפרגולה, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של הבית, בתוך המועד האמור, על הותרת הפרגולה על כנה, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

99. הנתבעת תחדול מלעשות שימוש ייחודי בחניה, וזאת בתוך 90 ימים מהיום. משטח החניה יוותר כרכוש משותף אשר ישמש את כלל בעלי הדירות בבית. אלא אם תתקבל החלטה אחרת של האסיפה הכללית של הבית, ובכלל זה החלטה על הריסתו, בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

100. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 8,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום, ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 23 במרץ, 2020, כז' באדר, תש"פ. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה